

1529246-30.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1529246-30.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529246-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2329765/2021 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 4218/2021 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DA CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1641.21

VISTOS.

EDSON DA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 19, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 11:40 horas, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5.700, Bom Retiro, nesta cidade e comarca da capital, guardava consigo 30 porções de maconha, com peso líquido de 76,3 gramas, 50 porções de cocaína, com peso líquido de 13,3 gramas, e 71 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 29,8 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 102 e a defesa preliminar devidamente apresentada.

Durante a instrução processual, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos

exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução máxima de dois terços; a pena no mínimo; fixação do regime inicial aberto com substituição por pena restritiva de direitos e, por fim, a concessão do direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 11, dando conta das 30 porções de maconha, das 50 porções de cocaína, das 71 pedras de crack, além da quantia de R\$ 549,00, encontrados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico, de fls. 23/26, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahydrocannabinol e cocaína.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos de sua defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia, o réu alegou que é apenas usuário e estava no local apenas para comprar drogas, fl. 10.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu forneceu sua versão dizendo que eu estava lá, os policiais chegaram, o rapaz que estava vendendo droga correu. Os policiais mandaram eu voltar porque não conseguiram pegar o rapaz que correu, que largou a bolsinha lá. Eles perguntaram se a droga era minha, eu disse que não, e o dinheiro era do meu trabalho. Não conhecia os policiais anteriormente.

Ocorre, porém, que os argumentos do acusado não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceu. O réu não apresentou qualquer versão plausível para sua prisão. Limitou-se a dizer o que todos dizem quando são surpreendidos em poder de grande quantidade de drogas, ou seja, que estava apenas passando quando foi abordado e detido, quando o verdadeiro traficante fugiu.

No entanto, não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, deixar o verdadeiro traficante fugir e, ao acaso, prender o réu e acusá-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga.

Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Mesmo, porque, não se pode crer que o réu estivesse com tamanha quantidade de drogas em seu poder, não fosse para o exercício da traficância.

Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita do réu ao avistar os policiais, o local conhecido como ponto de drogas, sua abordagem e a grande quantidade e variedade de drogas encontradas, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Guilherme

Simes Nunes e Christopher Duque de Andrade, ouvidos, em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que estávamos em patrulhamento no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando vimos uma aglomeração de pessoas. Optamos por averiguar, quando o réu, ao nos ver, dispensou uma pochete e tentou empreender fuga, porém, foi detido. Em poder do réu foi encontrado o dinheiro e no interior da pochete que ele havia dispensado foram encontradas as drogas. O outro rapaz que estava aparentemente comprando também foi detido, mas com ele nada foi encontrado. O réu confessou informalmente que estava na venda de drogas. Antes desses fatos o réu já havia sido preso pelos fatos. Reconheceram o réu.

Os policiais narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, o momento em que suspeitaram do denunciado que mexia numa pochete enquanto Daniel esperava ao seu lado. O momento em que os policiais desembarcaram da motocicleta e o réu tentou correr para o interior de um prédio, sua abordagem, o encontro do dinheiro em posse do réu, bem como das drogas dentro da pochete, tipo bolsinha, sua confissão informal, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, no sentido da ausência de carga probatória que convalide a adequação da condenação, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo, pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de

mercancia – Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, o fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários.

Destarte, não se evidenciou qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado responde por outro tráfico de entorpecentes, no entanto, ainda é primário e sem antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa. Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de crack, reduzo a pena base em 1/3, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida – 13 (treze) pedras de crack – justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3” (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar EDSON DA CONCEIÇÃO, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo, compareceu a todos os atos processuais, de maneira que faze-lo retornar aos sistemas carcerários mostra-se medida por demais drástica e desnecessária. De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social.

Não se pode perder de vista, ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram. No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: “Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos

precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum).”

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA